

1500353-48.2022.8.26.0081

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Comarca: Adamantina

Foro: Foro de Adamantina

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... as provas comprovam a prática do tráfico de drogas, assim, pugnou pela procedência da ação.

Por seu turno, a Defesa, fls. 222/229, apresentou alegações finais, alegando a ilicitude da prova constante dos autos e absolvição do réu por ausência de provas ou a desclassificação do tráfico de drogas para o crime de posse de droga para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Adamantina

Foro de Adamantina

1ª Vara

Avenida Adhemar de Barros, 133, Adamantina-SP - cep 17800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500353-48.2022.8.26.0081 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500353-48.2022.8.26.0081

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2065608/2022 - DISE- DEL.SEC.ADAMANTINA, 23488775 - DISE- DEL.SEC.ADAMANTINA, 2065608 - DISE- DEL.SEC.ADAMANTINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ CARLOS PEDRO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra LUIZ CARLOS PEDRO DA SILVA, denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que na data de 09 de março de 2022, por volta das 09h40min, na Rua Pernambuco, nº 299, Jardim Brasil, nesta cidade e comarca de Adamantina - SP, LUIZ CARLOS PEDRO DA SILVA, trazia consigo e guardava, para entrega a consumo de terceiros, o total de 4,58g (quatro gramas e cinquenta e oito centigramas) de cocaína, na forma de "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante, fls. 01/05, e teve sua prisão preventiva

decretada, conforme decisão no termo de audiência, fls. 110/113.

A denúncia foi oferecida em 08 de abril de 2022, fls. 159/161.

Determinada a notificação do denunciado para apresentação de defesa prévia, fls. 163.

O acusado foi devidamente notificado, tendo a defesa apresentado defesa prévia, fls. 173/174.

O Ministério Público apresentou manifestação, fls. 180.

A denúncia foi recebida em 22 de junho de 2022, não houve matéria preliminar e nem questões prejudiciais a serem apreciadas, sendo designada audiência de instrução, fls. 181/182.

Em audiência de instrução, fl. 209, foram inquiridas duas testemunhas da acusação e interrogado o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais sob a forma de memoriais escritos.

Por ocasião das alegações finais, fls. 213/218, o Ministério Público, em síntese, considerou provadas a materialidade e autoria do crime. Afirmou que as provas comprovam a prática do tráfico de drogas, assim, pugnou pela procedência da ação. Por seu turno, a Defesa, fls. 222/229, apresentou alegações finais, alegando a ilicitude da prova constante dos autos e absolvição do réu por ausência de provas ou a desclassificação do tráfico de drogas para o crime de posse de droga para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

Decido.

Preliminarmente, afasto a tese de ilicitude da prova constante nos autos. Isso porque os policiais militares empregaram os meios necessários e proporcionais que o caso necessitava, cientes das denúncias de tráfico de drogas realizado pelo réu e o modus operandi que corriqueiramente é empregado, aliado ao fato do réu tentar ocultar provas da materialidade delitiva, tentando engolir a droga apreendida em sua posse. Logo, nenhuma nulidade a ser reconhecida.

Nesse sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) - Condenação decretada - Recurso defensivo - Mensagens de celular observadas pelos policiais durante a abordagem - Prova lícita - Denúncia anônima confirmada pelos demais elementos dos autos - Preliminares afastadas - Materialidade e autoria bem demonstradas - Depoimentos firmes e substanciais dos policiais - Quantidade relevante de entorpecentes - Elementos probatórios que indicam a dedicação à atividade criminosa - Condenação de rigor - Pena-base fixada acima do mínimo legal - Aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 - Não cabimento - Circunstâncias que denotam o envolvimento habitual com o comércio ilícito de entorpecentes - Regime prisional fechado mantido - Incabível substituição da pena privativa de liberdade - Recurso improvido." (TJSP; Apelação Criminal 1500716-02.2020.8.26.0438; Relator (a): Fátima Vilas Boas Cruz; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Penápolis - 4ª Vara; Data do Julgamento: 10/05/2022; Data de Registro: 10/05/2022).

No mesmo sentido é o entendimento da E. 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo: "APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de drogas Condenação Recurso defensivo Mensagens de celular verificadas pelos policiais durante a abordagem Legitimação da busca no aplicativo do aparelho celular Prova lícita Preliminar afastada - Materialidade e autoria bem demonstradas Depoimentos firmes e detalhados dos policiais Quantidade e natureza das drogas incompatíveis com o mero uso Exculpatória genérica e carente de indícios que a corroborem Condenação de rigor Pena-base no mínimo legal Redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 aplicado na origem Regime fechado de rigor Inviável a substituição por pena restritiva de direitos Recurso defensivo desprovido." (TJSP; Apelação Criminal nº 1500444-70.2019.8.26.0073; Relator: Roberto Porto; Comarca: Avaré; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; DJE: 30/01/2020).

Pois bem.

Por primeiro, destaca-se o que se extrai das declarações das testemunhas prestadas em juízo, bem como do interrogatório do réu. Vejamos:

A testemunha Nelson Welton Fortunato, Policial Militar, declarou que existiam denúncias de que o réu realizava a mercancia de drogas no local dos fatos, por mais de um ano. Ele declarou que estavam em patrulhamento, quando abordaram o réu nas proximidades da Rua Pernambuco com a Rua Ceará. Que o réu estava com três pedras de "crack" na boca e manuseando o aparelho de telefonia celular no momento da abordagem. Que o réu as expeliu as pedras de "crack" no momento da abordagem. Que o aparelho de telefonia celular estava com o aplicativo de mensagens aberto no momento da abordagem, sendo possível constatar que o réu comunicava-se com uma pessoa de alcunha "Junior", com mensagens em que o réu dizia estar comercializando pedras de "crack" por R\$ 10,00 (dez reais). Que conduziram o réu até a casa em que ele ficava. Que esse local já era conhecimento dos policiais. Que nesse local havia um colchão com mais vinte pedras de "crack", com características idênticas às expelidas pelo réu no momento da abordagem. Que o réu declarou que o colchão era seu. Que a abordagem ocorreu pelo fato de o réu realizar gesto de esconder algo na boca ao avistar o patrulhamento policial. Que tanto a visualização das mensagens no aparelho de telefonia celular, quanto à revista na residência foram autorizadas pelo réu.

A testemunha Rodiney Borges Peres, Policial Militar, declarou que estavam em patrulhamento na Rua Pernambuco, quando avistaram o réu com um "telefone" na mão, momento em que também perceberam que ele colocou algo na boca. Que abordaram o réu e encontraram como ele três pedras de "crack" escondidas na boca. Que as pedras de "crack" estavam embaladas em um papel alumínio. Que no momento da abordagem chegaram mensagens no aparelho de telefonia celular do réu. Que o réu trocava mensagens com uma pessoa de alcunha "Junior". Que o réu dizia ao "Junior" que tinha "pedra de 10". Que realizaram entrevista com o réu. Que perguntarem onde o réu estava morando. Que o réu disse que morava com um pessoa de alcunha "Pio". Que perguntaram ao réu se eles poderiam se deslocar até a referida residência. Que o réu disse que sim. Que nesse local encontraram mais vinte pedras de "crack" no interior de um colchão, com as mesmas características das que foram encontradas com o réu. Que o réu negou que o entorpecente fosse dele. Que a abordagem foi realizada em razão do patrulhamento e do gestual do réu em esconder algo na boca.

O réu Luiz Carlos Pedro da Silva declarou que sabe do que está sendo acusado. Que trabalha na construção civil. Que recebe salário de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por mês. Que é solteiro e não tem filhos. Que já foi preso anteriormente por tráfico de drogas. Que cumpriu a pena. Que seria "réu confesso", confirmando a versão das testemunhas, embora a droga fosse para seu consumo. Que realmente havia comprado as três pedras de "crack". Que ao avistar os policiais, assustou-se e tentou correr e engolir as pedras de "crack". Que as pedras de "crack" eram para seu uso pessoal. Que foi conduzido até a sua casa e após diversas buscas encontraram mais vinte pedras de "crack", embaladas em um plástico. Que não permitiu o acesso as suas mensagens no aparelho de telefonia celular. Que não mora na residência em que foram encontradas as vinte pedras de "crack".

Tem-se no caso a acusação do cometimento do crime presente no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Os elementos existentes nos autos são suficientes para o decreto condenatório, anotando-se que os indícios iniciais se transformaram em prova segura.

A materialidade delitiva do tráfico de drogas restou devidamente comprovada, a autoria também é certa e recai sobre o réu.

É certo que o mero "trazer consigo" e "guardar" já é mais do que suficiente à configuração do tráfico, a teor do artigo 33 da Lei de Drogas: "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Nota-se que, em Juízo, o réu não negou a prática delituosa do tráfico, dizendo ele mesmo ser "réu confesso", embora dizer que a droga era para seu consumo.

Porém, a simples análise nos depoimentos das testemunhas, aliada as demais provas, confirma a traficância.

A alegação do réu de que a droga seria para seu consumo não prospera. Não se mostra minimamente plausível essa versão sustentada por ele, haja vista a quantidade de provas nos autos que comprovam a mercancia, como, por exemplo, a quantidade de droga, bem como as conversas no aplicativo de mensagens do celular do réu.

Os depoimentos prestados pelos Policiais Militares, responsáveis pela prisão do réu, de forma coerente, apontam a dinâmica dos fatos, além da situação observada que revelou a prática do delito.

Além disso, não há qualquer elemento concreto apto a enfraquecer a versão dos policiais, não restando qualquer indicação que pretendiam incriminar falsamente o réu, assim, entendo por comprovada a traficância.

Ressalta-se que o próprio réu dá credibilidade ao depoimento dos Policiais Militares.

Não há o que se falar em desclassificação para o crime de uso de drogas do artigo 28 da Lei 11.340/06 e nem para o §3º do artigo 33 da Lei 11.343/06, eis que a quantidade de droga apreendida, ou seja, 4,58g (quatro gramas e cinquenta e oito centigramas), acondicionada em 20 (vinte) pedras, vulgarmente conhecida por "crack", droga essa de alto potencial lesivo para a saúde pública e destrutivo para o usuário, aliada à existência de denúncias de que o réu praticava o tráfico na cidade, constituem circunstâncias que sustentam a conclusão, sem margem de erro, da prática do crime de tráfico, afastando a possibilidade de reconhecimento de mero porte ou que a conduta não tinha como objetivo o lucro.

É crível que o réu realmente era usuário de droga, mas tal circunstância, por si só, não afasta o fato de que ele, na ocasião, estava realizando o tráfico de droga, já que a destinação da droga apreendida era o comércio ilícito.

Nesse sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. Ausência de pedido de perícia na defesa preliminar e durante a instrução. Ausência de elementos que justifiquem a realização de exame. Mérito. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do acusado. Desclassificação. Impossibilidade. Quantidade de droga, forma de acondicionamento, circunstâncias do crime e da prisão que revelam a incompatibilidade de transporte para mero uso e evidenciam a venda e a destinação à mercancia. Penas e regime bem aplicados NEGADO PROVIMENTO AO APELO". (TJSP; Apelação 0001323-43.2016.8.26.0628; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taboão da Serra - Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018; Data de Registro: 30/11/2018).

Oportuno observar que o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 dispõe que "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Registra-se que o crack é uma das drogas mais viciantes e com maior potencial destrutivo, sendo um subproduto da cocaína vendido por um valor mais acessível, o que torna-o muito popular entre a população de baixa renda.

Não convence a tese defensiva de ausência de prova, pois a intenção do tráfico ilícito de drogas restou configurada.

Destaca-se o relatório de investigação (fls. 135/139) que analisou as conversas extraídas do celular do réu, comprovando de forma clara e objetiva a existência do seu envolvimento com o tráfico de drogas, e de maneira constante, vejamos:

Fls. 137 - "Na rede social Facebook, Messenger, Bate-papos, há uma troca de mensagens entre Luiz e o contato Junior Oliveira (imagem 6), dia 09 de março, das 09:11 horas às 09:45 horas, em que Luiz informa que tem "pedra de 10 reais"(imagem 7).

É de conhecimento bastante difundido que neste meio, "pedra" refere-se ao entorpecente "crack" e a data da conversa é a mesma que Luiz foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas, quando foi surpreendido com o mesmo tipo de entorpecente em sua posse e em sua residência" . (destaquei)

Fls. 138 - "Nota-se nas duas fotos armazenadas, o manuseio de entorpecentes e embalagens semelhantes às apreendidas com o indiciado, segue fotos ampliadas e recurso de "propriedade" das mesmas, com datas próximas a do Fato:" (destaquei)

Assim, repita-se, sintomaticamente, não há como negar a imputação de tráfico. Pois bem, em razão das circunstâncias em que se deu a prisão, não pairam dúvidas de que as substâncias entorpecentes eram destinadas à comercialização, devido às informações presentes nos autos, bem como a existência de um envolvimento do réu, em que o mesmo foi condenado e cumpriu pena, devido o cometimento do mesmo crime praticado supracitado na denúncia deste processo.

Por outras palavras, é evidente que o réu cruzou há muito a linha do trabalho lícito pelo ilícito.

Portanto, a somatória dos elementos de prova colhidos nos autos traz a certeza de que o réu "trazia consigo" e "guardava" drogas para entrega a consumo de terceiros na data dos fatos, praticando, em essência, o crime de tráfico, razão pela qual, de rigor é sua condenação.

Delineada a responsabilidade penal do réu pelo crime de tráfico de drogas, resta fixar a reprimenda devida.

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com os requisitos do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes (fls. 76/87), certo também que é reincidente, todavia estes elementos serão analisados em segunda fase. Assim a pena base será fixada no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, ante a agravante da reincidência, a pena base será elevada em 1/3, restando a pena fixada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa de reclusão. Ausentes atenuantes.

Na terceira fase de aplicação da pena, não há causa de aumento ou diminuição de pena.

Não pode ser aplicada ao caso a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, diante da reincidência, não se adaptando a essência da previsão ao caso.

Tratando-se de crime equiparado a hediondo (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), bem como pela reincidência do réu, este iniciará o cumprimento de sua pena no regime fechado.

Por efeito da pena aplicada e da reincidência, impossível conceder ao réu os benefícios do artigo 44 e 77 do Código Penal.

Por fim, anote-se que apreendido aparelho celular, conforme auto de exibição e apreensão (fl. 62).

Nesse sentido, o art. 243, parágrafo único da Constituição Federal preconiza o perdimento de bens apreendidos em decorrência do tráfico de drogas, veja-se: "Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º.

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei." (grifei)

Insta ressaltar que a Lei Antitóxicos impõe a inversão do ônus da prova ao réu, de modo que a ele, acusado de narcotráfico, compete demonstrar cabalmente a origem lícita do seu patrimônio.

Nesse sentido, estatui o art. 60, nos seus §§1º e 2º, da Lei 11.343/2006, que:

"Art. 60, §1º - Decretadas quaisquer das medidas previstas neste artigo, o juiz facultará ao acusado que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente ou requeira a produção de provas acerca origem lícita do produto, bem ou valor objeto da decisão.

§2º - Provada a origem lícita do produto, bem ou valor, o juiz decidirá pela sua liberação."

Ao comentar o §2º do referido artigo, assinala o renomado Prof. VICENTE GRECO FILHO: "Outra particularidade da lei é a de que há uma inversão do ônus da prova no §2º do art. 6º. Caberá ao acusado demonstrar a origem lícita dos bens e não à acusação a origem ilícita, que fica presumida pelos indícios suficientes". (Lei de Drogas Anotada, Ed. Saraiva, 2007, pág. 189).

É de rigor, portanto, o perdimento do bem utilizado no tráfico de drogas, no caso o aparelho de telefonia celular, eis que instrumento essencial na aquisição, negociação e distribuição da droga, além disso, não há prova segura de sua origem lícita.

Isto posto e considerando o tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE esta ação para condenar LUIZ CARLOS PEDRO DA SILVA, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a cumprir a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em REGIME FECHADO, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, cujo valor unitário fica fixado no mínimo legal da Lei de Drogas.

Estando o réu segregado, bem como mantidas e reforçadas as razões do perigo a ordem pública, não há razão para revogar a prisão preventiva. Dessa forma, não terá o direito de recorrer em liberdade. Comunique-se a prisão onde se encontra recolhido. Decreto, ainda, o perdimento do bem apreendido em decorrência da traficância, na forma acima fundamentada. Autorizo a incineração da droga, caso ainda não realizada.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

Adamantina, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA